



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0100/2014 **Sucre, 10 de enero de 2014**

SALA PLENA

Magistrada Relatora: Dra. Soraida Rosario Cháñez Chire
Acción de inconstitucionalidad abstracta

Expediente: 03609-2013-08-AIA
Departamento: Chuquisaca

En la **acción de inconstitucionalidad abstracta** interpuesta por **Juan Luis Gantier Zelada, Diputado del Estado Plurinacional de Bolivia**, demandando la inconstitucionalidad de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley del Presupuesto General del Estado (LPGE) Gestión 2013, por infringir las normas de los arts. 1, 8.I y II, 9.4, 14.II, 22, 46.I.1, 2 y II, 47.I, 108.1, 2 y 3, 109.II, 115.II, 116.I y II, 117.I, 120.I, 306.I, II y III, 308.I y II, 318.II, 323.I, 334.4 y 410.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE); 1, 2, 7, 8, 10, 11 y 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 2 y 3; y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 5, 6 y 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 5, 6, 23 y 24 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la acción

Por memorial presentado el 20 de mayo de 2013, cursante de fs. 3 a 18, el accionante, en su condición de Diputado del Estado Plurinacional de Bolivia, expone los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Relación sintética de la relación

Las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la LPGE Gestión 2013, introduce reformas al Código Tributario Boliviano agravando la situación de los contribuyentes, especialmente de los microempresarios bolivianos, atentando los valores y principios de la Constitución Política del Estado.

La Disposición Adicional Quinta de la LPGE, es contraria a la Constitución Política del Estado, porque: a) Mantiene “la clausura inmediata” prescindiendo del debido proceso; b) Agrava las sanciones previstas anteriormente, c) Suprime la posibilidad de convertir la sanción de clausura en multa; y d) Establece la clausura definitiva como sanción.

La norma impugnada mantiene la clausura inmediata del negocio prescindiendo del debido proceso previo a cualquier sanción, “invirtiendo” (sic) el principio de presunción de inocencia, suprimiendo la posibilidad de ejercer el derecho a la defensa y restringiendo el derecho al trabajo, porque el hecho de clausurar un negocio en forma inmediata implica suprimir el derecho al trabajo.

La limitación de los derechos fundamentales está supeditada al estricto cumplimiento de garantías constitucionales, procesales, judiciales y jurisdiccionales, entre estas el debido proceso legal en sus elementos de presunción de inocencia, a la defensa, derecho a un proceso previo a la sanción, derecho a contar con el tiempo suficiente y los medios para asumir defensa, derecho a presentar prueba para su valoración, derecho a la motivación, congruencia, derecho a la doble instancia.

Manifiesta que, la norma impugnada permite que los funcionarios públicos con una sola actuación, intervengan oficiosamente, califiquen el hecho e impongan la penalidad, prescindiendo totalmente del debido proceso, porque la intervención y clausura suelen durar menos de cuatro minutos, lapso imposible para cumplir el debido proceso; además, la norma no contempla la participación del sancionado, presume la culpabilidad directa, prescinde de la comunicación previa con la acusación o denuncia, no permite el ejercicio del derecho a la defensa y permite que se emita una sanción sin la debida motivación. La norma contraría abiertamente el debido proceso previsto en los arts. 115.II y 117 de la CPE, por que establece un trámite brevísimo impidiendo que el sancionado tenga la posibilidad de disponer del tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa y a comunicarse con un abogado defensor.

La norma, también agrava las sanciones previstas anteriormente, suprime la

posibilidad de convertir la sanción de clausura en multa y establece la clausura definitiva como sanción.

La norma tributaria anterior, establecía como sanción la clausura definitiva, no obstante ella se podía convertir en una multa aunque elevada, permitiendo al microempresario continuar con su negocio abierto, hoy la norma impugnada excluye la posibilidad de esa conversión, agravando la situación de los mismos, porque se los obliga a cerrar en forma definitiva sus fuentes de trabajo.

El modelo económico plural del Estado Plurinacional de Bolivia, está orientado a mejorar la calidad de vida, para ello pregona el vivir bien de todos los bolivianos (art. 306), reconoce la iniciativa privada y la libertad de empresa (art. 308); además como política económica, reconoce y prioriza el apoyo a la estructura asociativa de micro, pequeñas y medianas empresas productoras (art. 318); la política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa (art. 334). Todas estas normas constitucionales reflejan el interés y compromiso del Estado para proteger la actividad de los microempresarios, pero la Disposición Adicional Quinta, contraría abiertamente esos mandatos constitucionales, porque al establecer la clausura definitiva como sanción, suprime totalmente esos derechos fundamentales; debido a que la clausura implica el cese de las actividades comerciales, privación de ingresos económicos y en definitiva privación del derecho al trabajo.

Por otra parte, manifiesta que la Disposición Adicional Quinta de la LPGE, Gestión 2013 contempla la intervención oficiosa de la administración tributaria mediante operativos de control, estableciendo un procedimiento anticonstitucional, hiper sumarísimo, discrecional y arbitrario; exige como único requisito, la elaboración de un acta en presencia de un testigo de actuación, cuando se advierta una contravención tributaria de ipso facto procede el funcionario a la clausura como sanción, sin dar la mínima oportunidad al sancionado de poder defenderse, explicar la circunstancia y presentar descargos. Este procedimiento, genera la prepotencia, el maltrato y la extorsión a vendedores contribuyentes, porque es un instrumento de coacción que atenta contra el principio de presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el derecho a ser oído y el derecho a ser sometido a un proceso legal previo.

La sanción de clausura definitiva que contempla la norma impugnada, es un contrasentido flagrante a los valores universales de justicia, igualdad, dignidad,

respeto, bienestar común, suma qamaña, ñandereko, tekokavi, la seguridad jurídica, proporcionalidad, capacidad económica, solidaridad y universalidad.

Todos tienen la posibilidad de rehabilitarse, hasta los que vulneran bienes jurídicos superiores como la vida, el patrimonio, el honor, después de cumplir la sanción para luego volver al entorno social; en cambio, a los microempresarios, la norma impugnada los condena a morir de hambre privándolos de sus fuentes de trabajo, porque el procedimiento contemplado, es totalmente parcializado y dirigido a castigar sin permitirles ejercer sus derechos y ser sancionados sin proceso previo.

Con relación a la disposición adicional sexta, manifiesta que ésta crea un nuevo delito tributario, mal configurado, como es la “penalización de la comercialización de facturas y documentos equivalentes” solo cuando no se ha “realizado el hecho generador”. El problema, yace en la delegación de responsabilidad que hace la administración tributaria al contribuyente y hasta a terceros, porque existe situaciones que escapan a la buena fe del comprador y del vendedor contribuyente, por ello el mero hecho de detentar una factura ilegal, siendo su procedencia inicialmente lícita, da lugar a ser acusado como coadyuvar o participar indirectamente en el ilícito tributario.

La sanción que emite la norma cuestionada es desproporcional, porque no diferencia la participación directa o indirecta. Esta norma por todo lo manifestado, vulnera los valores de justicia, igualdad, dignidad, respeto, seguridad jurídica al incorporar un nuevo tipo penal ambiguo que pretende descargar la responsabilidad de la administración tributaria, en desmedro de los derechos del contribuyente.

El mantener las normas, implica una ponderación de valores, fines, bienes colectivos, directrices organizacionales, derechos y garantías en coincidencia con el principio de conservación de la norma establecido en el Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina la presunción de constitucionalidad; pero en el caso, se hace imposible conservar las normas impugnadas, puesto que la incompatibilidad con la Constitución Política del Estado es total.

Por los fundamentos expuestos, solicita que previo trámites, se dicte Sentencia Constitucional declarando la inconstitucionalidad de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la LPGE Gestión 2013.

I.2. Admisión y citaciones

Por AC 0213/2013-CA de 18 de junio, cursante de fs. 19 a 23, la Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional, admitió la acción de inconstitucionalidad abstracta planteada por Juan Luis Gantier Zelada, Diputado de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, ordenando que la acción y el Auto de Admisión se pongan en conocimiento de Álvaro Marcelo García Linera, Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, como personero del Órgano que generó la norma impugnada, lo cual se cumplió el 12 de julio de 2013 (fs. 51).

I.3. Alegaciones del personero del órgano que generó la norma impugnada

Álvaro Marcelo García Linera, Vice Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por memorial presentado el 29 de julio de 2013, cursante de fs. 56 a 62 vta., formuló sus alegatos en los siguientes términos: **1)** El procedimiento legislativo es un conjunto de pasos que deben seguir los Órganos de gobierno, al momento de producir una norma o bien para realizar una modificación de una norma ya existente, siendo el único límite a la producción normativa, la Constitución Política del Estado como referencia de acción reguladora; **2)** La Ley de Presupuesto General del Estado de la Gestión 2013, ha observado el procedimiento legislativo que la norma fundamental le impone al legislador; **3)** La Norma Suprema del art. 158.I.3 faculta al Órgano Legislativo emitir leyes en sumisión a la Constitución Política del Estado, en ese sentido no se puede cuestionar de inconstitucional una norma que deviene del mandato expreso de la Ley Fundamental; **4)** Por mandato constitucional, la aprobación del Presupuesto General del Estado, es atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional; **5)** De conformidad al art. 298.I.21 de la CPE, la codificación sustantiva y adjetiva tributaria se encuentra al interior del universo de competencias privativas del nivel central del Estado, en consecuencia el desarrollo legislativo hecho en la Ley del Presupuesto General del Estado de la Gestión 2013, en lo que respecta a materia tributaria, encuentra su génesis normativo en la norma constitucional citada; **6)** Las normas tributarias, al ser el sostén económico primario del país, encuentran en el bien común su razón de ser y para su eficacia completa, pueden determinar condiciones especiales, en base a la procura de hacer eficaces las disposiciones que la norma de tributación establece, lo contrario sería dejar en incertidumbre el desarrollo de la política tributaria y como consecuencia de ésta, dejar en suspenso el ejercicio de derechos que son de peso mayor por la naturaleza que les son inmanentes; **7)** Para garantizar el cumplimiento de los intereses generales

que corresponden al Estado, la administración no solo cuenta con potestades reguladoras, sino también con el poder de sancionar las infracciones al ordenamiento jurídico-administrativo; potestad que tiene como campo de acción el marco de la Constitución Política del Estado; esta potestad de imponer sanciones para quienes vulneran la legalidad administrativa, persigue garantizar la observancia plena de la ley y de las limitaciones y deberes que se imponen a los ciudadanos por el sistema de normas o los actos administrativos de obligatorio cumplimiento; **8)** La actividad sancionadora es una de las bases del Estado Constitucional de Derecho, con ello se garantiza el cumplimiento exacto de las determinaciones del ordenamiento jurídico administrativo y por el otro se garantiza el ejercicio pleno de los derechos a favor del administrado; **9)** La infracción a la norma administrativa o su incumplimiento, aparejan la sanción, misma que puede ser de diversas formas, pecuniario, suspensión o prohibición definitiva o temporal de actividades o del ejercicio del derecho, los comisos o decomisos, todas estas por separado o algunas coincidentes entre sí, caso en el cual la administración impone una sanción que es contenedora de dos efectos, uno económico y otro de comiso, este último no es más que la sustracción de los bienes de forma definitiva al incumplido por haber quebrantado el orden público, base primera del Estado de Derecho; **10)** Todas las condiciones que establece la Constitución Política del Estado a favor de la administración para emitir sanciones, se encuentran cumplidas por las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta LPGE Gestión 2013; **11)** Las disposiciones adicionales, al interior de una ley son excepciones, dispensas o reservas a la aplicación de la norma o de alguno de sus preceptos o la determinación legislativa de una situación de derecho que requiera por necesidad ser regulada en la norma principal; **12)** Las disposiciones adicionales tienen una condición de vigencia, la relación, por fuerza, con la norma que le hace de habilitadora, ante esto es común advertir que las normas de presupuesto tengan relación estrecha con las disposiciones aduaneras; **13)** Toda disposición adicional, transitoria y final, al ser una excepción a la regla, cumple con los requisitos de orden constitucional; en cuanto a la forma, cuando su aprobación es sujeta al criterio del legislador, en sus dos etapas de discusión en grande y en detalle; **14)** La modificación al interior de cualquier sistema de normas, implica la necesidad de rediseñar un mandato de regulación por uno nuevo, que obedezca a los parámetros de constitucionalidad, no existe prohibición alguna a la modificación, salvo la pertinencia, en base a ella la modificación debe ser coherente con la norma modificada, la modificación legislativa es una facultad derivada de la producción legislativa, que la teoría denomina facultad legislativa derivada negativa, ya que si bien no elimina la norma, la desplaza por una nueva regulación, cuya previsión se encuentra en la norma fundamental; **15)** La disposición adicional quinta contiene tres situaciones jurídicas: **i)** La referida a la obligación de la Administración Tributaria de verificar el correcto

cumplimiento de la emisión de factura, mediante operativos de control; esta actividad es propia de la administración tributaria; **ii)** La referida a la sanción propiamente dicha frente a un comportamiento ilegal de parte de quien contravenga una obligación tributaria; y, **iii)** La tercera situación es una expresión de la potestad sancionadora ante la reincidencia, con la condición de la máxima aplicada, momento en el que la sanción será la clausura definitiva del local intervenido; entonces, si existe una situación jurídica que se desprende de las atribuciones propias de la autoridad, si la sanción impuesta condice con la potestad sancionadora del Estado y si la sanción mayor es una expresión de gradación sancionatoria, mal puede cuestionarse de inconstitucional, ya que ésta contiene incólumes los presupuestos constitucionales; **16)** Respecto a la Disposición Adicional Sexta, el nivel central del Estado, tiene competencia privativa en materia Tributaria y Penal, por ello cuestionarle la creación de un tipo penal en materia tributaria no tiene sentido práctico en control normativo de constitucionalidad; y, **17)** No es cierto que el tipo penal introducido sea deficiente, en cuanto a técnica de regulación penal, porque cuenta con la acción, tipicidad, antijuricidad, imputabilidad y culpabilidad, necesaria en toda configuración penal.

Por lo expuesto, pide se declare constitucionales las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la LPGE Gestión 2013, observados como inconstitucionales.

I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Recibido el expediente el 20 de mayo de 2013, por la Unidad de Registro de Ingresos y Causas (fs. 18), la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, por AC 0213/2013- CA de 18 de junio, admitió la acción de inconstitucionalidad abstracta, disponiendo ponerla en conocimiento del personero legal del Órgano emisor de la norma impugnada, Álvaro Marcelo García Linera, Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, a objeto de que pueda formular los alegatos que considere necesarios, acto procesal que se realizó el 12 de julio de 2013, conforme informa el formulario de citaciones y notificaciones cursante a fs. 51.

Realizado el sorteo correspondiente y radicada la causa ante el Magistrado Relator, éste al no haber obtenido el conceso necesario en su proyecto, solicitó segundo sorteo y devolvió el expediente a la Comisión de Admisión, disponiéndose el segundo sorteo, conforme proveído cursante a fs. 90, el 5 de diciembre de 2013, recayendo la causa en este despacho.

Asimismo, mediante decreto constitucional de 11 de diciembre de 2013, en aplicación del art. 7.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), se solicitó al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la remisión de las actas de

debates de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2013, así también se requirió que la Secretaría Técnica del Tribunal Constitucional Plurinacional, que por la Unidad de Tratados Internacionales, emita un informe sobre la Legislación comparada respecto al “al ámbito de Regulación de la Ley de Presupuesto General de un Estado”, así como sobre la jurisprudencia existente en los Tribunales Internacionales respecto al mismo tema, disponiéndose la suspensión del plazo conforme previene el art. 7.II del Código citado.

Habiendo sido remitida la documentación solicitada, se admitió la misma y se dispuso la reanudación del cómputo del plazo por decreto de 8 de enero de 2014, a cuyo efecto la presente Resolución se pronuncia dentro de plazo legal.

II. CONCLUSIONES

II.1. Normas consideradas inconstitucionales

La Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2013, en su Disposición Adicional Quinta señala, lo siguiente:

“Se modifica el primer párrafo del Artículo 170 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, con el siguiente texto:

‘La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta actuación. Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo II del Artículo 164 de este Código. En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del local intervenido’”.

La Disposición Adicional Sexta de la misma Ley señala: “Se incorpora el Artículo 177° ter a la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, con el siguiente texto:

‘Artículo 177° ter (EMISIÓN DE FACTURAS, NOTAS FISCALES Y DOCUMENTOS EQUIVALENTES SIN HECHO GENERADOR). El que de manera directa o indirecta, comercialice, coadyuve o adquiera

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes sin haberse realizado el hecho generador gravado, será sancionado con pena privativa de libertad de dos (2) a seis (6) años”.

II.2. Normas constitucionales consideradas infringidas

Se consideran vulnerados los siguientes artículos de la Constitución Política del Estado:

II.2.1. “Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”.

II.2.2. “Artículo 8.

- I.** El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble).
- II.** El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien”.

II.2.3. “Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley:

(...)

4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”.

II.2.4. “Artículo 14.

(...)

II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona”.

II.2.5. “Artículo 22. La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”.

II.2.6. “Artículo 46.

I. Toda persona tiene derecho:

1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna.
2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias.

II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas”.

II.2.7. “Artículo 47.

I. Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo”.

II.2.8. “Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos:

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes
2. Conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución.
3. Promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución”.

II.2.9. “Artículo 109.

(...)

II. Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley”.

II.2.10. “Artículo 115.

(...)

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.

II.2.11. “Artículo 116.

- I.** Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado.
- II.** Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible”.

II.2.12. “Artículo 117.

- I.** Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada”.

II.2.13. “Artículo 306.

- I.** El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos.
- II.** La economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa.
- III.** La economía plural articula las diferentes formas de organización económica sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. La economía social y comunitaria

complementará el interés individual con el vivir bien colectivo”.

II.2.14. “Artículo 308.

- I.** El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país.
- II.** Se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales, que serán reguladas por la ley”.

II.2.15. “Artículo 318.

(...)

- II.** El Estado reconoce y priorizará el apoyo a la organización de estructuras asociativas de micro, pequeñas y medianas empresas productoras, urbanas y rurales”.

II.2.16. “Artículo 323.

- I.** La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria”.

II.2.17. “Artículo 334.

(...)

- 4.** Las micro y pequeñas empresas, así como las organizaciones económicas campesinas y las organizaciones o asociaciones de pequeños productores, quienes gozarán de preferencias en las compras del Estado”.

II.2.18. “Artículo 410.

- I.** Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución.
- II.** La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra

disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país, la aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:

1. Constitución Política del Estado.
2. Los tratados internacionales
3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena
4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes”.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante impugna de inconstitucionales las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la LPGE Gestión 2013, por ser presuntamente contrarios a los arts. 1, 8.I y II, 9.4, 14.II, 22, 46.I.1, 2 y II, 47.I, 108.1, 2 y 3, 109.II, 115.II, 116.I y II, 117.I, 120.I, 306.I, II y III, 308.I y II, 318.II, 323.I, 334.4 y 410.I y II de CPE; 1, 2, 7, 8, 10, 11 y 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 2 y 3; y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 5, 6 y 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”; 14 y 15 del PIDCP; 5, 6, 23 y 24 del PIDESC.

En consecuencia, corresponde a este Tribunal establecer si las infracciones denunciadas son evidentes.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de inconstitucionalidad abstracta

Las acciones de inconstitucionalidad se encuentran reguladas en nuestra Constitución Política del Estado, así en su art. 132, señala que: “Toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la Acción de Inconstitucionalidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley”;

En el Código Procesal Constitucional, también se encuentra establecido las acciones de inconstitucionalidad, así en su art. 72 señala: “Las Acciones de Inconstitucionalidad son de puro derecho y tienen por objeto declarar la inconstitucionalidad de toda norma jurídica incluida en una ley, decreto o

cualquier género de resolución no judicial que sea contraria a la Constitución Política del Estado, a instancia de las autoridades públicas señaladas en el presente Código”.

En su art. 73, establece los tipos de acciones de inconstitucionalidad cuando señala lo siguiente: “Las acciones de Inconstitucionalidad podrán ser:

1. Acción de Inconstitucionalidad de carácter abstracto contra leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales.
2. Acción de Inconstitucionalidad de carácter concreto, que procederá en el marco de un proceso judicial o administrativo cuya decisión dependa de la constitucionalidad de leyes estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales”.

En su art. 74, establece la legitimación activa para interponer la acción de inconstitucionalidad abstracta y señala que: “Están legitimadas y legitimados para interponer la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta, la Presidenta o el Presidente del Estado Plurinacional, Cualquier miembro de la Asamblea Legislativa Plurinacional o de los Órganos Legislativos de las Entidades Territoriales Autónomas, las máximas autoridades ejecutivas de las Entidades Territoriales Autónomas, así como la Defensora o el defensor del Pueblo”.

Conforme a las normas citadas precedentemente, la acción de inconstitucionalidad abstracta, es una acción constitucional de control correctivo o a *posteriori*, de las disposiciones legales vigentes, acción a través de la cual el Tribunal Constitucional Plurinacional, verifica la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales promulgadas, con los principios, valores, derechos fundamentales y normas orgánicas de la Constitución Política del Estado Plurinacional, con el objetivo de depurarla del ordenamiento jurídico en caso de comprobarse su incompatibilidad. A su vez se constituye en una acción directa, porque a través de ella la autoridad legitimada efectúa la impugnación sin que la supuesta incompatibilidad esté vinculada a la solución de un caso concreto.

III.2. Alcances del control de constitucionalidad normativo

En cuanto a los alcances, resulta preciso referirnos a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que sobre el particular se ha desarrollado, así la SC 0019/2006 de 5 de abril, siguiendo el criterio expresado en la

SC 0051/2005 de 18 de agosto, en cuanto a los alcances del control normativo posterior de constitucionalidad que ejerce a través del recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad señaló que: *"...abarca los siguientes ámbitos: a) la verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales impugnadas con las normas de la Constitución Política del Estado, lo que incluye el sistema de valores supremos, principios fundamentales, así como los derechos fundamentales consagrados en dicha Ley Fundamental; b) la interpretación de las normas constitucionales así como de la disposición legal sometida al control desde y conforme a la Constitución Política del Estado; c) el desarrollo de un juicio relacional para determinar si una norma legal es o no conforme con las normas constitucionales; determinando previamente el significado de la norma legal por vía de interpretación; y d) la determinación de mantener las normas de la disposición legal sometida al control"*, aclarando que el Tribunal Constitucional en: *"...su labor se concentra en el control objetivo de constitucionalidad de las disposiciones legales objetadas"*. Esto implica que a través del control normativo posterior de constitucionalidad se debe: verificar, si las disposiciones legales impugnadas son compatibles con las normas, el sistema de valores supremos, principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado; interpretar la norma sometida a control y la norma constitucional desde y conforme a la Constitución Política del Estado; realizar un juicio relacional entre la norma legal impugnada y las normas constitucionales determinando el significado de la disposición legal sometida a control con la finalidad de mantener o retirarla del ordenamiento jurídico.

III.3. La potestad administrativa sancionadora en el marco de nuestro modelo de Estado

En virtud a nuestro modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, la potestad sancionadora del Estado se encuentra limitada por los principios valores, derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado y en los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos.

Efectivamente, debe considerarse que nuestro modelo de Estado tiene, además de características propias como la plurinacionalidad, la interculturalidad y la descolonización, elementos que lo inscriben dentro del marco de los Estados Constitucionales actuales, en los que se apuesta por Constituciones plurales, garantizadas y normativas, con un amplio catálogo de principios, valores, derechos y garantías fundamentales, que se encuentran dotadas de garantías específicas de

interpretación, que hacen que la parte axiológica y dogmática de la Constitución Política del Estado tenga un peso decisivo, no sólo en cuanto a su aplicación directa, sino también porque se constituyen en fundamento y límites de las diferentes funciones del poder público.

Así, respecto a la facultad sancionadora del Estado, constituida no solo por el derecho penal, sino también por el derecho administrativo sancionador, es evidente que, en virtud al principio de supremacía constitucional (art. 410 de la CPE), las normas sustantivas y procesales que se crean para el efecto, deben estar enmarcadas en las normas constitucionales, donde tiene un rol fundamental la parte dogmática de la Constitución Política del Estado, pero también en las normas que forman parte del bloque de constitucionalidad.

Entonces, el legislador y las autoridades administrativas, en la Reglamentación, no poseen una discrecionalidad absoluta al momento de legislar y de definir qué conductas serán consideradas delitos, infracciones o contravenciones, definir las sanciones y el procedimiento para el efecto, sino que deben respetar el sustento axiológico y dogmático de la Constitución Política del Estado, en especial los derechos y garantías de las personas que se constituyen en el fundamento y límite del poder sancionador del Estado y, de no hacerlo, se abre la vía del control normativo de constitucionalidad, ya que, en el marco de nuestro Estado Plurinacional y Comunitario, que recoge los postulados del Estado Constitucional, el carácter normativo de la Constitución Política del Estado se encuentra garantizado a través del Tribunal Constitucional Plurinacional.

En ese sentido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional contenida en la SCP 0142/2012 de 14 de mayo, estableció que, en virtud a nuestro modelo de Estado, tanto el razonamiento de las juezas y los jueces, como de las servidoras y los servidores públicos del Estado del nivel central y de las entidades territoriales autónomas, cuando ejerzan potestades administrativas, entre ellas, las potestades sancionadoras de la administración pública del nivel central y de las entidades territoriales autónomas, *"...debe partir de la Constitución, de sus normas constitucionales-principios atendiendo las características del nuevo modelo de Estado que los sustentan"*; normas constitucionales-principios que, de acuerdo a la SCP 0112/2012 de 27 de abril *"son la pluralidad de valores, principios, derechos fundamentales no sólo individuales (liberales y sociales) sino un amplio catálogo de derechos y garantías, principios y valores plurales y colectivos que la constitución representa como un pacto de postulados distintos y hasta veces contradictorios, pero que al final deben coexistir"*.

Conforme a ello, respecto al valor normativo de la Constitución, la jerarquía de las normas constitucionales y su obligatoriedad, precisó que: *"...las normas constitucionales-principios, establecidos en el texto constitucional tienen validez normativa, prelación jerárquica y son obligatorias respecto a las normas constitucionales-reglas y con mayor con relación respecto a las normas legales-reglas (contenidas en las leyes en sentido general sustantivas o procesales) por el sólo hecho de estar inscritas en la Constitución, una Constitución ideada dentro del modelo de Estado Constitucional, con todo lo que ello implica".*

A partir de dichos razonamientos las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0140/2012 y 0142/2012 hicieron referencia a los límites del ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, que ***"...encuentran una barra de contención en el respeto de garantías mínimas, siendo una de ellas, el debido proceso"*** (las negrillas son nuestras) que de acuerdo a las mismas sentencias, *"...controla y limita el campo de acción de la potestad sancionadora del Estado, a efectos de evitar una actividad arbitraria de la administración pública que se torne en ilícita. Ello en aras de la búsqueda de la materialización de los valores, en los que se sustenta el Estado Constitucional de Derecho Plurinacional Comunitario e Intercultural (art. 8.II de la CPE), que en lo conducente, al ámbito sancionador disciplinario, principalmente son el de justicia y armonía".*

III.4. El debido proceso en la Constitución Política del Estado y su aplicación al ámbito administrativo sancionador

La jurisprudencia constitucional ha señalado que el Estado, en determinados supuestos, otorga a la Administración Pública la potestad sancionadora, cuyas normas que la regulan constituyen el llamado Derecho Administrativo Sancionador. *"Esta potestad sancionadora, por los fines que persigue, se bifurca en dos: la disciplinaria y la correctiva. La primera se dirige a proteger los propios intereses de la Administración como organización (eficiencia, puntualidad, etc.); sus sanciones están dirigidas a sus funcionarios, así como a personas vinculadas a la Administración por especiales deberes y relaciones jurídicas. La segunda, se dirige a imponer sanciones a la generalidad de ciudadanos que pudieran transgredir los deberes jurídicos que las normas les imponen como administrados. Este es el caso de las infracciones que establece por ejemplo, el Código Tributario en su Título III, en el que se establecen sanciones específicas para quienes incumplan los mandatos y prohibiciones contenidos en la referida norma*

legal (Derecho administrativo penal). En estos supuestos, la Administración tiene facultad para imponer sanciones, las que, en algunos casos, tienen igual o mayor gravedad que las establecidas en el Código Penal (este es el caso de las multas), pero tal potestad no alcanza en ninguno de los casos, a imponer la pena privativa de libertad, la cual está reservada al órgano judicial correspondiente" (las negrillas son nuestras) (SC 0757/2003-R de 4 de junio).

En ese ámbito, de acuerdo a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y siguiendo el entendimiento contenido en la SC 0035/2005 de 15 de junio, **cuando el legislador atribuye a la administración facultades sancionadoras, no debe proceder por puro arbitrio, sino que deben cumplir determinadas condiciones para ser constitucionales, observando las garantías básicas de orden material y formal.**

Conforme a ello, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en establecer que el debido proceso debe ser observado no solo en la vía judicial, sino en toda la esfera administrativa sancionadora (SSCC 787/2000-R, 953/2000-R, 820/01-R, 685/2002-R, 0757/2003-R, entre muchas otras). **Así, la SC 685/2002-R de 11 de junio, ha establecido que los derechos a la seguridad, a la petición, a la defensa y a la garantía del debido proceso, "...es aplicable no sólo al ámbito judicial sino también al administrativo cuando se tenga que someter a una persona a un procedimiento en el que deberá determinarse una responsabilidad; por lo mismo, todo proceso de la naturaleza que fuere deberá ser sustanciado con absoluto resguardo y respeto de los derechos y garantías del procesado"**(las negrillas son agregadas).

Por su parte, la SC 0757/2003-R, respecto a las garantías del proceso administrativo, señaló:

"Si partimos del hecho de que la sanción administrativa supone la privación de algún derecho o la afectación de algún interés (en el caso de autos, los previstos en el Título III del Código Tributario), y que tal privación debe ser el resultado de la comprobación, conforme a derecho, de un hecho ilícito que se le atribuye, correspondiendo por tanto enjuiciar una conducta, no cabe duda que el proceso administrativo en cuestión debe estar revestido de las garantías procesales consagradas en la Constitución. Así lo ha entendido la jurisprudencia de este Tribunal en las SC 618/2003, al señalar que "...[la garantía del debido proceso, que consiste en el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo,

en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (SC 418/2000-R), la cual no es aplicable únicamente al ámbito judicial, sino que debe efectivizarse en todas las instancias en las que a las personas se les atribuya -aplicando el procedimiento establecido por ley- la comisión de un acto que vulnere la normativa vigente y es obligación ineludible de los que asumen la calidad de jueces, garantizar el respeto a esta garantía constitucional (SC 731/2000-R). De ello se determina que las reglas del debido proceso no sólo son aplicables en materia penal, sino a toda la esfera sancionadora, y dentro de ella se encuentra la materia administrativa disciplinaria (SSCC 787/2000-R, 953/2000-R, 820/2001-R, y otras)"; garantías que, con igual razón, deben estar presentes en el proceso administrativo penal".

En similar sentido, la SC 0042/2004 de 22 de abril, señaló que:

"...toda actividad sancionadora del Estado, sea en el ámbito jurisdiccional o administrativo, debe ser impuesta previo proceso, en el que se respeten todos los derechos inherentes a la garantía del debido proceso, entre los cuales se encuentra el derecho a la defensa, que implica a su vez, entre otros elementos, la notificación legal con el hecho que se le imputa al afectado, y con todas las actuaciones y resoluciones posteriores, la contradicción y presentación de pruebas tendentes a desvirtuar la acusación, la asistencia de un defensor, el derecho pro actione ó a la impugnación; asimismo, el derecho a la defensa, se relaciona directamente con los derechos a la igualdad de las partes ante la ley y ante su juzgador, al juez natural y a la seguridad"(las negrillas son añadidas).

Por su parte, la SC 0287/2011-R de 29 de marzo, estableció que ***"El debido proceso, es el derecho de toda persona a un proceso justo, ante el juez natural previamente determinado, proceso que deberá ser llevado a cabo sin dilaciones de una manera equitativa a procesos instaurados a sus pares, dentro del cual se garantice al administrado o procesado la certeza de una notificación con la totalidad de la sindicación a efectos de una defensa efectiva, permitiendo ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia, presentar las excepciones que correspondan a criterio suyo, sobre las cuales en todos los casos deberá existir pronunciamiento expreso del Tribunal o autoridad a cargo del proceso disciplinario"*** (las negrillas nos pertenecen).

Dichos razonamientos fueron reiterados por la SC 0498/2011-R de 25 de abril, en la que se señaló que: ***"El proceso administrativo, debe hallarse***

impregnado de todos los elementos del debido proceso, que deben ser respetados en su contenido esencial, en cuanto al juez natural, legalidad formal, tipicidad y defensa irrestricta '...La doctrina en materia de derecho sancionador administrativo es uniforme al señalar que éste no tiene una esencia diferente a la del derecho penal general y por ello se ha podido afirmar que las sanciones administrativas se distinguen de las sanciones penales por un dato formal, que es la autoridad que las impone, es decir sanciones administrativas, la administración y sanciones penales, los tribunales en materia penal'. (García de Enterría, E. y Fernández, T. R., Curso de derecho administrativo, II, Civitas, Madrid, 1999, página 159)".

El contenido jurisprudencial anotado, fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0140/2012, 0143/2012, 0169/2012 y 0851/2012, entre muchas otras.

Así, la SCP 0140/2012 de 9 de mayo, a partir de las normas de la Constitución Política del Estado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tuvo el siguiente razonamiento respecto al debido proceso en el ejercicio de la actividad sancionadora del Estado:

"a) El debido proceso, está reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

*El art. 115.II de la CPE, reconoce que: '**El Estado garantiza el derecho al proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones**'.*

A su vez, el art. 117.I de la CPE, consagra: 'Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada'.

Por su parte el art. 8 de La CADH, señala:

- 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil,*

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

- a) Derecho del inculcado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;*
- b) Comunicación previa y detallada al inculcado de la acusación formulada;*
- c) Concesión al inculcado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;*
- d) Derecho del inculcado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;*
- e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculcado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;*
- f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;*
- g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable,*
- h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.*

3. La confesión del inculcado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

4. El inculcado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia (...).

*b) La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), -que forma parte del bloque de constitucionalidad según la SC 0110/2010-R de 10 de mayo-, interpretando **el art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) ha entendido que el respeto y protección del debido proceso es también aplicable en el ámbito de la potestad sancionadora de la Administración Pública.***

Así en el caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá (Sentencia de 2 de febrero de 2001, Fondo, Reparaciones y Costas) entendió que: '... cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal', derecho que '... es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con este deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas' (párrafos 124 y 127).

El mismo órgano interamericano de protección derechos humanos, en el caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú (Sentencia de 31 de enero de 2001, Fondo, Reparaciones y Costas) a partir de la interpretación del art. 8 de la CADH, señaló:

'El respeto a los derechos humanos constituye un límite a la actividad estatal, lo cual vale para todo órgano o funcionario que se encuentre en una situación de poder, en razón de su carácter oficial, respecto de las demás personas. Es, así, ilícita, toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención. Esto es aún más importante cuando el Estado ejerce su poder sancionatorio, pues éste no sólo presupone la actuación de las autoridades con un total apego al orden jurídico, sino implica además la concesión de las garantías mínimas del debido proceso a todas las personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción, bajo las exigencias establecidas en la Convención' (párrafo 68).

'Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula 'Garantías Judiciales', su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, "sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales" a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos' (párrafo 69).

'Ya la Corte ha dejado establecido que a pesar de que el citado no especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene también el derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal' (párrafo 70).

'De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo. Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un 'juez o tribunal competente' para la 'determinación de sus derechos', esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana'. (párrafo 71) (las negrillas son nuestras).

La Sentencia glosada, concluyó que: *"El Tribunal Constitucional aplicó este entendimiento a infinidad de casos que fueron resueltos en su jurisdicción entendiendo que todos los principios y garantías propias del derecho penal se aplican también extensivamente en el ámbito administrativo sancionador".*

Conforme a la jurisprudencia glosada, la sanción administrativa debe ser el resultado de un debido proceso, en el que se respete su contenido esencial, garantizando el derecho a la defensa del administrado, para que éste, una vez conocido el cargo por el que se le acusa, tenga la posibilidad de presentar las pruebas que desvirtúen la acusación, así como la posibilidad de impugnar la resolución sancionatoria aplicada contra él.

III.5. Los principios limitadores del poder punitivo del Estado

Conforme se ha señalado, el poder punitivo del Estado se encuentra limitado por los derechos y garantías de las personas; más aún cuando el legislador define qué conductas serán consideradas delictivas y, en ese ámbito, deben considerarse los principios limitadores de dicho poder, respecto a la criminalización de las conductas, a través de la correspondiente tipificación.

Uno de estos principios es el de intervención mínima, del que derivan otros principios como el de idoneidad, proporcionalidad en sentido estricto y subsidiariedad; principios todos ellos que precautelan los derechos fundamentales de las personas y de las colectividades, limitando al mínimo el poder punitivo del Estado, bajo el entendido, que el derecho penal es una de las ramas del derecho más violentas, como

anota acertadamente Zaffaroni, "se sustenta en la ilusión de la solución de gravísimos problemas sociales, que en realidad no los resuelve sino que, por el contrario, generalmente potencia, pues no hace más que criminalizar algunos casos aislados, producidos por las personas más vulnerables al poder punitivo. Este no es un efecto inofensivo del discurso, puesto que la ilusión de solución paraliza o neutraliza la búsqueda de soluciones reales o eficaces....Puede asegurarse que la historia del poder punitivo es la de las emergencias invocadas en su curso, que siempre son serios problemas sociales. En ese sentido se ha hablado correctamente de una emergencia perenne o continua, lo que es fácilmente verificable: el poder punitivo pretendió resolver el problema de la brujería, de la herejía, de la prostitución, del alcoholismo, de la sífilis, del aborto, de la insurrección, del anarquismo, del comunismo, de la tóxicodependencia, de la destrucción ecológica, de la economía subterránea, de la corrupción... Cada uno de esos conflictivos problemas se disolvió (dejó de ser problema), se resolvió por otros medios o no lo resolvió nadie, pero absolutamente ninguno de ellos fue resuelto por el poder punitivo".

Ahora bien, de acuerdo al principio de intervención mínima, el derecho penal sólo debe intervenir en los casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes. En otras palabras, en virtud a este principio, las sanciones penales deben ser las indispensables, en beneficio de otras sanciones o incluso la tolerancia de los ilícitos más leves.

El principio de intervención mínima está íntimamente vinculado al principio de idoneidad que de acuerdo a Alessandro Baratta, obliga al legislador a realizar un atento estudio de los efectos socialmente útiles que cabe esperar de la pena: "sólo subsisten las condiciones para su introducción si, a la luz de un riguroso control empírico basado en el análisis de los efectos de normas similares en otros ordenamientos, de normas análogas del mismo ordenamiento y en métodos atendibles de prognosis sociológica, aparece probado o altamente probable algún efecto útil, en relación a las situaciones en que se presupone una grave amenaza a los derechos humanos".

También debe hacerse mención al principio de proporcionalidad concreta o de adecuación del costo social, en virtud del cual los costos sociales de la pena deben ser valorados desde el punto de vista de la incidencia negativa que la pena puede tener sobre aquellas personas que constituyen su objeto, sus familias y ambiente social y sobre la sociedad misma. Así, entonces, como anota Baratta, se debe considerar que la violencia penal puede agravar y reproducir los conflictos en las áreas

específicas en que aquélla interviene, añadiendo el autor que “existen casos muy evidentes en los cuales la introducción de medidas penales produce problemas nuevos y más graves que aquellos que la pena pretende resolver (...) y en los que ésta puede ser considerada como una variable esencial en la estructura de un problema social complejo”.

En el ámbito del costo social de la intervención penal debe considerarse además, los efectos desiguales de la sanción penal y sobre su ámbito familiar y social, que dependen, del *estatus* social de las o los condenados, pues conforme a la selectividad del sistema penal, la sanción penal es mayor en los estratos sociales más bajos.

Otro de los principios que debe mencionarse, es el de subsidiariedad, en virtud al cual sólo se justifica la criminalización cuando no existen otros medios o alternativas para enfrentar el conflicto. En otras palabras sólo se justifica la intervención del poder punitivo del Estado cuando no existen modos no penales de intervención para responder a situaciones en las cuales se hallan amenazados los derechos humanos. Conforme a ello, se debe demostrar que la respuesta penal no es sustituible por otros modos de intervención de menor costo social.

Finalmente, es preciso hacer referencia al **principio de proporcionalidad de la pena** según el cual, “las medidas represivas adoptadas para conjurar la lesión o puesta en peligro del bien jurídico deben ser proporcionales a éste, a la gravedad del delito cometido, el contenido del injusto, al mal causado, **y a la mayor o menor responsabilidad del autor**”.

El juicio de proporcionalidad debe ser ineludiblemente efectuado por el legislador, quien deberá sopesar, al momento de tipificar el delito, el carácter doloso o culposo del hecho, la consumación o la tentativa, las diferentes formas de participación en el delito, en síntesis el mayor o menor reproche que se le pueda atribuir a quien participó en la comisión del ilícito penal. Así, la proporcionalidad **“impone la necesidad de tratar desigualmente lo que es desigual en una valoración material y político criminal. Las reacciones del sistema punitivo no tienen uniformidad ciega”**.

El principio de proporcionalidad de las penas se funda en la dignidad humana, por cuanto se deben proscribir aquellas penas que resultan desproporcionadas y que solo atiendan al desvalor del resultado, es decir aspecto objetivo del acto, el resultado, sin atender el lado subjetivo del comportamiento humano, a la forma y la modalidad en que se perpetró

la ofensa. En ese entendido, el legislador debe buscar un equilibrio entre ambos criterios (subjetivo y objetivo, disvalor del acto y del resultado) para lograr una legislación penal equilibrada y proporcionada.

Conforme a los argumentos anotados, la función legislativa está limitada por los principios antes anotados, en el marco del respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales reconocidas en nuestra Constitución Política del Estado, los cuales se constituyen en el fundamento y límite del poder punitivo del Estado, de ahí que la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0085/2012 de 16 de abril, haya establecido que el control de constitucionalidad en sus diferentes ámbitos debe efectuarse a la luz del principio de razonabilidad, en este caso aplicado a la legislación penal, destinado a materializar los valores igualdad y justicia que se encuentran en el contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución Política del Estado.

III.6. Análisis del caso y juicio de constitucionalidad de las normas demandadas de inconstitucionales

De acuerdo a la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada ante este Tribunal Constitucional Plurinacional, el accionante demanda la inconstitucionalidad de las normas impugnadas con los siguientes argumentos: **i)** Que la Disposición Adicional Quinta de la LPGE Gestión 2013, faculta a los funcionarios de la Administración Tributaria a sancionar directamente, con la clausura de la actividad económica, sin que exista una resolución fundamentada y sin poder ejercer el derecho a la defensa y menos otorga la posibilidad de presentar pruebas; y, **ii)** Que la Disposición Adicional Sexta de la precitada Ley, crea el “delito tributario mal configurado”, por penalizar la comercialización de facturas o documentos equivalentes, cuando no se ha realizado el hecho generador; empero, permite la comercialización de facturas o documentos equivalentes que sean verdaderos y, finalmente, las sanciones establecidas son desproporcionales, sin diferenciar el grado de participación directa o indirecta.

Conforme a ello, y sobre la base de los argumentos cuestionados, a continuación se efectuará el test de constitucionalidad de cada una de las disposiciones legales impugnadas.

III.6.1. Sobre la Disposición Adicional Quinta de la LPGE Gestión 2013

La Disposición Adicional Quinta de la LPGE Gestión 2013, que modifica el primer párrafo del art. 170 del Código Tributario Boliviano (CTB), establece lo siguiente:

“La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta actuación. Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo II del Artículo 164 de este Código. En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del local intervenido”.

Conforme se aprecia, la Disposición Adicional impugnada contiene cuatro partes: La **primera** referida a la posibilidad de que la Administración Tributaria verifique de oficio el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control; la **segunda**, que sostiene que la Administración debe elaborar un acta donde se identifique a la contravención, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero responsable y otros datos; la **tercera**, que determina que una vez elaborada el acta, se procederá a la clausura inmediata del negocio, de acuerdo a las sanciones establecidas en el parágrafo II del art. 164 del CTB, y la **cuarta**, que establece que, en caso de reincidencia, se procederá a la clausura definitiva del local intervenido.

Ahora bien, de conformidad a los argumentos de la acción de inconstitucionalidad formulada, que han sido resumidos al inicio del Fundamento Jurídico III.6 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se impugnan las dos últimas partes; es decir, la tercera y cuarta parte, vinculadas a la posibilidad de clausurar inmediatamente el negocio, sin la existencia de un debido proceso, y la que determina la clausura definitiva del local intervenido en caso de reincidencia; consecuentemente, el test de constitucionalidad únicamente versará sobre estas dos

últimas partes y no así sobre las dos primeras partes del artículo; porque, conforme se tiene señalado, el accionante no formuló los correspondientes cargos de inconstitucionalidad con relación a las dos primeras partes de dicha disposición legal.

Efectuada dicha aclaración, se ingresa al análisis de la constitucionalidad de la norma que determina que una vez elaborada el acta, se procederá a la clausura inmediata del negocio, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

a) El art. 108 de la CPE, establece como deberes de las bolivianas y los bolivianos: "7. Tributar en proporción a su capacidad económica, conforme con la ley"; es en virtud de este deber constitucional que el legislador tiene facultad para regular los deberes tributarios de las personas naturales o jurídicas, estableciendo la forma en que se debe cumplir la obligación tributaria y las sanciones aplicables en caso de incumplimiento; sanciones que, indudablemente tienen fundamento constitucional, por cuanto el art. 325 de la CPE, contenido en la Sección I "Política Fiscal", del Capítulo Tercero, Título I, Organización Económica del Estado, de la Cuarta Parte de la CPE, establece que: "El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, el agio, la usura, el contrabando, la evasión impositiva y otros delitos económicos conexos serán penados por ley". En ese sentido, corresponde al legislador aprobar las leyes que hagan efectivo dicho mandato constitucional, estableciendo los instrumentos que permitan exigir a los particulares el cumplimiento de esa obligación, pues de ella depende el desarrollo de los fines y funciones del Estado y la vigencia plena de una de las características de nuestro estado, como es su **carácter social** (art. 1 de la CPE).

Efectivamente, debe considerarse que la actividad sancionatoria de la Administración en materia tributaria, persigue fines constitucionales legítimos, si se considera que es precisamente a través de la recaudación de impuestos que se logrará una inversión pública en beneficio de los ciudadanos, de donde se desprende que para el cumplimiento efectivo de los fines trazados por el Estado, como ser la de garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad, la protección, el acceso a la educación, la salud, el trabajo, entre otros, es indispensable que los ciudadanos cumplan con su

deber de tributar y, en caso de no hacerlo, que se apliquen las sanciones previstas en la Ley, en el marco de los principios que rigen la actividad de la Administración Pública, como la legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, honestidad, responsabilidad y resultados, pero también en los principios específicos de la política fiscal, como el de igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria (art. 323 de la CPE).

Es entonces, por la naturaleza constitucional del deber de tributar, así como los fines y funciones que debe cumplir el Estado a través de la recaudación de impuestos, que la existencia en la ley, de sanciones administrativas, así como su aplicación, se encuentran plenamente justificadas constitucionalmente; Sin embargo, el cargo de inconstitucionalidad que se formula en la presente acción es si la clausura del negocio, como sanción administrativa, puede ser aplicada de manera directa, sin un debido proceso, sin dar la oportunidad al administrado de ejercer su derecho a la defensa. Para responder a dicha interrogante, se debe señalar que el Código Tributario Boliviano, al hacer referencia a las contravenciones tributarias, establece en el art. 161 a las siguientes sanciones: multa, **clausura**, pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas tributarias, la prohibición de suscribir contratos con el Estado por el término de tres meses a cinco años, comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado, y suspensión temporal de actividades.

Ahora bien, la clausura es una de las sanciones más graves para los administrados, por cuanto no solo supone la afectación al patrimonio del administrado, sino también, afecta a otros derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, y puede incidir directa o indirectamente en los derechos de terceras personas. Así, por ejemplo, la clausura puede afectar no sólo al propietario de un negocio, sino además, a todos quienes dependan de él económicamente, como puede ser su familia y los trabajadores dependientes, inclusive, puede afectar de manera indirecta a terceras personas, en los supuestos en que dichas empresas o instituciones presten algún servicio público.

De ahí que, por la intensidad de la afectación de los derechos, la clausura es considerada como una sanción que reviste gravedad para el administrado y, por lo mismo, es indispensable que el accionante sea escuchado para ejercer su derecho a la defensa.

Por otra parte, debe considerarse que tanto en el ámbito del derecho penal como en el ámbito del derecho administrativo sancionador, al que le son aplicables los principios de aquél, aunque en menor intensidad, rige el principio de culpabilidad, que se asienta en la dignidad de las personas; principio en virtud del cual está vedada la responsabilidad sin culpa, es decir, la responsabilidad puramente objetiva (responsabilidad por los resultados), debiendo en todo caso considerarse que la regla es que para la imposición de las sanciones administrativas, se exija por lo menos la culpa, y sólo de manera excepcional se pueda sancionar por pura responsabilidad objetiva, tomando en cuenta la naturaleza de la sanción y el grado de afectación a los derechos del administrado.

- b)** La Disposición Adicional Quinta de la LPGE Gestión 2013, faculta a la Administración Tributaria a imponer la sanción de clausura sin previamente constatar los motivos y las razones que pudieron haber generado dicha contravención, y si bien el acta de clausura cumple la función de una resolución sancionatoria, en ella se omiten las exigencias del debido proceso; puesto que, la norma demandada de inconstitucional no concede al administrado el derecho a la defensa, por el cual éste pueda ser escuchado por una autoridad competente; asimismo, tampoco se le otorga oportunidad alguna para presentar pruebas, antes que su actividad comercial sea clausurada, restringiéndose al administrado la posibilidad de contar con el tiempo y los medios necesarios para su defensa.

Con tales argumentos, y considerando la afectación de los derechos que conlleva la clausura, conforme se tiene explicado, la norma impugnada vulnera ciertamente el derecho al debido proceso; por otro lado, si bien es posible la impugnación del acta por el cual se ordenó la clausura, dicha permisión es posterior a la consumación de la sanción, cuando ya el derecho a la defensa fue violentado, y como consecuencia de ello la

penalidad fue materializada; no obstante que, como se ha visto en el Fundamento Jurídico III.4 del fallo, tanto la Norma Suprema, como las normas del bloque de constitucionalidad establecen que las sanciones administrativas, y más aún aquellas que afectan con mayor intensidad los derechos fundamentales, deben ser impuestas previo proceso.

Debe señalarse que la vulneración del derecho al debido proceso no encuentra justificativo en la finalidad de luchar contra la evasión fiscal, que se encuentra prevista en el art. 325 de la CPE, pues ésta bajo ninguna circunstancia puede suprimir un derecho fundamental, como efectivamente sucede con la disposición legal que ahora se analiza. En ese sentido, si bien el legislador pudo haber considerado la clausura de los locales comerciales como sanción tendiente a luchar contra la evasión fiscal, debió precautelar la vigencia de los derechos fundamentales, garantizando el debido proceso, para que el administrado tenga la oportunidad de contrarrestar las acusaciones de la administración tributaria, ofrecer sus descargos y pruebas en el ejercicio del derecho a la defensa, exponiendo ante las autoridades correspondientes las razones y motivos por las que incurrió en dicha falta; entonces, comprobada la contravención tributaria, sin necesidad de afectar a los derechos fundamentales y garantías constitucionales, resultaba legítima la medida de clausura del establecimiento comercial, siempre que dicha penalidad cumpliera con las exigencias y estándares de un proceso justo y equitativo; es decir, que la sanción haya surgido de un proceso, en el que se respete su contenido esencial, garantizando el derecho a la defensa del administrado, para que éste, una vez conocido el cargo por el que se le acusa, tenga la posibilidad de presentar las pruebas que desvirtúen la acusación, así como la posibilidad de impugnar la resolución sancionatoria aplicada contra él.

Consiguientemente, conforme a los razonamientos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la imposición de la sanción de clausura del establecimiento comercial tiene como requisito de validez el respeto de los derechos fundamentales, y que emerja de un debido proceso dotado de sus elementos esenciales. En ese orden de cosas, la directa imposición de la sanción de clausura de locales comerciales, prescindiendo de las garantías

mínimas que le asisten a los administrados, vulnera efectivamente el debido proceso previsto en los arts. 115.II y 117.I y el derecho a la defensa previsto en el art. 119, todos de la CPE; asimismo, tal medida afecta el derecho al trabajo de los administrados, porque con la clausura del local comercial, efectivamente se ven restringidos en generar recursos económicos y, con ello incluso se estaría ante una afectación de otros derechos conexos, como la alimentación, dejando de lado el mandato constitucional de proteger el derecho al trabajo en condiciones estables, equitativas y satisfactorias en todas sus formas; consiguientemente, la norma de la disposición legal impugnada que determina que concluida la actuación, **procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el parágrafo II del art. 164 del CTB**, debe ser expulsada del ordenamiento jurídico.

Los razonamientos antes señalados también deben ser aplicados para la norma de la Disposición Adicional Quinta que dispone que en caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del local intervenido; toda vez que una sanción de tal magnitud, que afecta el derecho al trabajo, bajo ninguna circunstancia puede ser aplicada sin un debido proceso, en el que se respeten los elementos esenciales anotados precedentemente y, por lo mismo, también debe ser expulsada del ordenamiento jurídico.

- c) Los mismos argumentos, por conexitud, deben ser aplicados a la primera parte del inc. 2) del art. 162.II del CTB, que sostiene:

“II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto por este Código (...).

2) **La no emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y en la omisión de inscripción en los registros tributarios, verificadas en operativos de control tributario**” (negrillas añadidas).

Efectivamente, dicha norma prevé la **aplicación directa de sanciones**, sin la existencia de un debido proceso, **en los casos de no emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes**; sanción, que, de acuerdo al art. 164 del CTB, consiste en la clausura del establecimiento donde

se desarrolla la actividad gravada y que se encuentra vinculada directamente con la norma cuya inconstitucionalidad ha sido comprobada en el presente análisis; la Disposición Adicional Quinta, conforme se ha analizado, hace referencia a la clausura inmediata del negocio cuando la Administración Tributaria verifique el incumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control.

Entonces, conforme a los argumentos desarrollados precedentemente, la primera parte del inc. 2) del art. 162.II del CTB lesiona el derecho al trabajo, así como los derechos y garantías previstas en los arts. 115, 117 y 119 de la CPE; puesto que, la sanción de clausura debe ser aplicada necesariamente a través de un proceso administrativo sancionador, en el que el administrado tenga la oportunidad de ejercer sus derecho a la defensa; consiguientemente, debe declararse su inconstitucionalidad, por conexitud, exhortando al Órgano Legislativo a que, en el plazo de seis meses, regule un procedimiento administrativo sancionador que responda a la naturaleza de la infracción aquí analizada, referida a la no emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, que garantice el contenido esencial de la garantía del debido proceso, en los términos aquí explicados.

III.6.2. Sobre la Disposición Adicional Sexta de la LPGE Gestión 2013

La Disposición Adicional Sexta de la LPGE Gestión 2013, incorpora el art. 177 del CTB, conforme al siguiente texto:

“Artículo 177° ter (EMISIÓN DE FACTURAS, NOTAS FISCALES Y DOCUMENTOS EQUIVALENTES SIN HECHO GENERADOR). El que de manera directa o indirecta, comercialice, coadyuve o adquiera facturas, notas fiscales o documentos equivalentes sin haberse realizado el hecho generador gravado, será sancionado con pena privativa de libertad de dos (2) a seis (6) años”.

Conforme se aprecia, la Disposición Adicional Sexta de la Norma Supra, crea un tipo penal, en el cual, la conducta típica está constituida por las siguientes acciones alternativas: **comercializar, coadyuvar o adquirir** facturas notas fiscales o documentos equivalentes, sin que se hubiere realizado el hecho generador. **Para las tres conductas antes descritas, se establece una**

sola pena: privación de libertad de dos a seis años.

Ahora bien, conforme se ha desarrollado en el Fundamento Jurídico III.5 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el legislador, al momento de legislar y de definir qué conductas serán consideradas delictivas, no posee una discrecionalidad absoluta, sino que debe respetar el sustento axiológico y dogmático de la Constitución Política del Estado, fundamentalmente los derechos y garantías de las personas que se constituyen en el fundamento y límite del poder punitivo del Estado.

Así, se estableció que uno de los principios es el de **proporcionalidad de la pena** según el cual, ésta debe ser proporcional a la lesión o la puesta en peligro de los bienes jurídicos que protege el derecho penal, debiendo el legislador sopesar, al tipificar el delito, el carácter doloso o culposo del hecho, la consumación o la tentativa, las diferentes formas de participación en el delito, en síntesis el mayor o menor reproche que se le pueda atribuir a quien participó en la comisión del ilícito penal.

En el tipo penal creado por la Disposición Adicional Sexta de la LPGE Gestión 2013, no se ha respetado dicho principio, pues no se efectúa distinción alguna entre las diferentes acciones tipificadas como delito, aplicándoles a todas ellas la misma sanción penal; sin considerar que entre la comercialización, la adquisición y el coadyuvar en dichas actividades, existen diferencias sustanciales en cuanto a la intensidad de la ofensa al bien jurídico, la forma de participación y, en consecuencia, el mayor reproche penal; aspectos que debieron estar necesariamente diferenciados en el tipo penal, pues de lo contrario, no solo se afecta a la dignidad de las personas (art. 22 de la CPE), sino también el principio-derecho y garantía a la igualdad (arts. 8.II y 14 de la CPE) que implica que supuestos iguales deben ser tratados de manera igual y que, al contrario, los supuestos diferentes, deben merecer un tratamiento diferenciado; así, en la norma analizada, acciones diferentes tienen una misma sanción penal, es decir, reciben el mismo tratamiento, cuando, a partir de la valoración individualizada de las diferentes acciones, en razón a los criterios señalados con anterioridad, debe existir un reproche penal diferente para cada una de las acciones típicas.

De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, comercialización, implica "dar a un producto

condiciones y vías de distribución para su venta”, “poner a la venta un producto”; lo que supone, entonces que, quien comercializa es una persona dedicada a la venta de un determinado producto. En el caso del tipo penal analizado, el sujeto activo, en la primera acción típica, debe ser la persona dedicada a la venta de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes sin haberse realizado el hecho generador.

Por su parte, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia, adquirir, implica comprar algo con dinero y, por tanto, en el tipo penal que se analiza, el sujeto activo es la persona que compra las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes sin haberse realizado el hecho generador.

Finalmente, de acuerdo al mismo Diccionario coadyuvar, implica contribuir, asistir o ayudar a la consecución de algo y, en ese sentido en el tipo penal que se estudia, el sujeto activo es la persona que ayuda en la comercialización o adquisición de las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes sin haber realizado el hecho generador.

De las descripciones antes anotadas, se concluye que no existe proporcionalidad entre las diferentes acciones típicas y la igual sanción anotada para todas ellas; pues, por una parte, es mayor el injusto de quien comercializa las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, sin que se hubiere realizado el hecho generador, que de quien simplemente las adquiere, y por otra parte, no se efectúa una adecuada distinción respecto a los partícipes en el hecho, sancionando al que presta colaboración como si fuera autor, sin distinguir si se trata de una cooperación determinante para la comisión del delito supuesto en el cual es correcto considerarlo como autor, de acuerdo al art. 20 del Código Penal (CP), o si se trata de una cooperación no determinante para la comisión del hecho (supuesto en el cual se sanciona como complicidad de acuerdo al art. 23 del CP).

En mérito a lo anotado, la norma impugnada, efectivamente lesiona el principio de dignidad contenido en el art. 22 de la CPE, el principio-derecho y garantía a la igualdad, prevista en los arts. 8 y 14 de la CPE; que son la base del principio de proporcionalidad de las penas, así como los principios de seguridad jurídica y legalidad, último de los cuales, en una de sus manifestaciones,

exige que la ley sea cierta, clara precisa y accesible al pueblo y que se traduce en el principio de taxatividad, que tiene por finalidad dotar de seguridad jurídica a los miembros de la sociedad. En ese sentido, lo entendió la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0034/2006 de 10 de mayo, que señaló: *"...serán contrarias al principio de taxatividad aquellas normas que configuran los presupuestos de hecho de manera abierta, difusa, discrecional o indeterminada, quedando en poder de los jueces regular efectivamente los supuestos"*.

Efectivamente, debe señalarse que, en mérito al principio de taxatividad, las conductas típicas deben estar claramente definidas y precisadas en el tipo penal, sin lugar a confusión; más aún cuando se advierte que las acciones descritas contenidas en la Disposición Adicional Sexta que se analiza, podrían subsumirse en los tipos penales descritos en el Capítulo III, Falsificación de Documentos en General, del Título IV, Segunda Parte del Código Penal y en los delitos tributarios previstos en el Código Tributario Boliviano.

Por lo expuesto, la Disposición Adicional Sexta de la LPGE Gestión 2013, debe ser expulsada del ordenamiento jurídico, exhortando al Órgano Legislativo a que en el futuro, considere los principios de taxatividad, igualdad, seguridad jurídica y proporcionalidad de las penas, además del principio de intervención mínima del que derivan los principios de idoneidad, proporcionalidad en sentido estricto y subsidiariedad; principios todos ellos que precautelan los derechos fundamentales de las personas y de las colectividades, y que deberán ser analizados ampliamente a través del procedimiento legislativo previsto en el Capítulo Segundo, Título I, Segunda Parte de la Constitución Política del Estado; pues, en el ámbito penal, en el marco del principio democrático (art. 1 de la CPE) que sustenta al principio de legalidad penal, la definición de las conductas consideradas delictivas y sus respectivas sanciones, deben estar establecidas necesariamente en una ley, como producto de la decisión de los representantes del pueblo, mediante un suficiente debate o discusión parlamentaria.

Por los argumentos expresados precedentemente, tanto la parte in fine de la Disposición Adicional Quinta como la totalidad de la Disposición Adicional Sexta de la LPGE Gestión 2013, deben ser declaradas inconstitucionales, con los efectos previstos en el art. 78.II.4 del Código Procesal Constitucional; por otra

parte, corresponde declarar la inconstitucionalidad, por conexitud de la primera parte del inc. 2) del art. 162.II del CTB.

POR TANTO

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.1 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, declara:

1. La INCONSTITUCIONALIDAD de la frase de la Disposición Adicional Quinta de la Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2013, que señala:

“Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo II del Artículo 164 de este Código. En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del local intervenido”.

La declaratoria de inconstitucionalidad de la frase señalada, no implica la declaratoria de inconstitucionalidad del contenido del parágrafo II del art. 164 del Código Tributario Boliviano, por no haberse sometido a control de constitucionalidad.

2. La INCONSTITUCIONALIDAD de la Disposición Adicional Sexta de la Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2013.

3. La INCONSTITUCIONALIDAD por conexitud de la frase, “La no emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y”, del art. 162.II inc. 2) del Código Tributario Boliviano.

4. Se EXHORTA al Órgano Legislativo, a que en el plazo de seis meses, regule el procedimiento administrativo sancionador que responda a la naturaleza de la contravención de la no emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, verificadas en operativos de control tributario; en tanto se proceda con la regulación de dicho procedimiento sancionador y en el marco de una interpretación previsor, se aplicará **el procedimiento contravencional establecido en el art. 168 del Código Tributario Boliviano.**

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

No intervienen el Presidente, Dr. Ruddy José Flores Monterrey y la Magistrada Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez, ambos por ser de voto disidente.

Fdo. Dra. Soraida Rosario Cháñez Chire
MAGISTRADA

Fdo. Dra. Mirtha Camacho Quiroga
MAGISTRADA

Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños
MAGISTRADA

Fdo. Efren Choque Capuma
**MAGISTRADO CORRESPONDE A LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL
PLURINACIONAL 0100/2014 (Viene de la página 34).**

Fdo. Tata Gualberto Cusi Mamani
MAGISTRADO